

1500067-45.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... com anotações da contabilidade do tráfico. Informalmente, ambos admitiram a prática do tráfico de drogas.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela enorme quantidade e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Auto de exibição e apreensão às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500067-45.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500067-45.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Visto.

Trata-se de ação penal na qual ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material.

Narra a denúncia (fls. 156/159) que, no dia 05 de janeiro de 2022 e em datas anteriores, em horário incerto, na Rua Sebastião Felipe da Silva, altura do n.º 19, Vila Menck, nesta cidade e comarca de Osasco, ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado à fl. 04, com fotografia à fl. 51, e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado à fl. 05, com fotografia à fl. 52, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2022 e em datas anteriores, em horário incerto, na Rua Sebastião Felipe da Silva, altura do n.º 19, Vila Menck, nesta cidade e comarca de Osasco, ANDERSON DO NASCIMENTO

ANCELMO, qualificado à fl. 04, com fotografia à fl. 51, e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado à fl. 05, com fotografia à fl. 52, agindo em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, traziam consigo drogas, consistentes em 02 (duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 34,49g, 49 (quarenta e nove) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 109,0g, 147 (cento e quarenta e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 80,1g, e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 4,33g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, para consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 10/11, laudos de constatação às fls. 14/16 e 17/20, fotografias às fls. 33/38 e 45/49 e laudo de exame químico-toxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Segundo o apurado, os denunciados, que são irmãos, constituíram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo certo que ambos guardavam os entorpecentes no imóvel situado no local dos fatos e exerciam a contabilidade das drogas que eram comercializadas.

No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram os denunciados sentados no meio fio, estando ambos em poder de bolsas de ombro e uma pochete.

Ao notar a presença policial, EDILSON entrou em um imóvel e ANDERSON ali permaneceu. Diante disso, os agentes da lei abordaram ANDERSON e, em revista pessoal, encontraram com ele, em sua bolsa, duas porções de maconha e um aparelho celular.

Em seguida, os policiais solicitaram ao dono do imóvel que o abrisse, o que foi feito, oportunidade em que EDILSON saiu, porém sem portar a pochete que trazia consigo, tendo ele indicado aos policiais militares o local em que a havia dispensado.

Recuperada a pochete, os agentes da lei constataram que ela continha mais entorpecentes, consistentes em 49 (quarenta e nove) porções de maconha, 147 (cento e quarenta e sete) porções de cocaína, e 25 (vinte e cinco) porções de crack, além da quantia de R\$ 205,00 (duzentos e cinco reais), em notas trocadas, e um caderno com anotações da contabilidade do tráfico. Informalmente, ambos admitiram a prática do tráfico de drogas.

Pela forma de acondicionamento das drogas, pela enorme quantidade e pelas demais circunstâncias do fato criminoso, demonstrou-se que as drogas se destinavam à venda para consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01.

Auto de exibição e apreensão às fls. 10/11.

Laudos de constatação às fls. 14/16 e 17/20.

Folhas de antecedentes criminais e certidões em nome dos denunciados às fls. 63/66 e 66/68.

Embora as prisões em flagrante dos acusados tenham sido convertidas em preventivas em sede de plantão judiciário (fls. 76/81), com mandados de prisão cumpridos à fls. 96/100 e 101/105, este Juízo, às fls. 108/113, concedeu aos acusados liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 108/113). Alvarás de soltura cumpridos às fls. 133/137 e 138/142.

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, bem como ajuizou cautelar inominada criminal para o fim de atribuir efeito ativo ao

recurso (fls. 128/129).

Aplicado ao feito o rito comum ordinário, a denúncia foi recebida às fls. 160/167, no dia 26 de janeiro de 2022.

Embora não tenham sido pessoalmente citados, os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 178, por meio de Defesa devidamente constituída nos autos (fls. 61 e 62). Não foi suscitada qualquer questão preliminar e, quanto ao mérito, reservou-se, a Defesa, o direito de se manifestar em momento oportuno.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 183/187, oportunidade em que foi designada AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO PRESENCIAL PARA O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 16h.

Folhas de antecedentes e certidões às fls. 203/216.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas de acusação e os réus, ao final, foram interrogados.

Em debates a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates, a Defesa requereu o reconhecimento da confissão, regime aberto e pena restritiva, sendo afastada a associação criminosa.

É relatório.

Fundamento e decido.

A - Preliminarmente, anoto que não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais a ponto de tornar a prova ilícita. A abordagem policial não foi tão somente baseada em "tirocínio" dos agentes públicos ou somente em "nervosismo", o que denotaria o mais puro subjetivismo, mas sim em comportamento efetivo, vale dizer, porque os réus ao virem a viatura, ambos com pochete em local de tráfico, um permaneceu no local, com o qual fora encontrada droga e o outro correu para uma residência de terceira pessoa, sendo que, com este, também foram encontradas drogas. Assim, cumprido o standard do art. 244 do CPP para atuação policial.

B - Do mérito

A ação penal é parcialmente procedente, devendo os réus serem absolvidos quanto ao crime do art. 35 da lei de drogas.

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudos periciais (fls. 222/225, 226/228, 229/231 e 232/234).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que os réus, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que pequena, traziam entorpecentes destinados a terceiras pessoas.

Os réus ouvidos em juízo confessaram a autoria delitiva. Ambos afirmaram que são irmãos e que, tendo em vista que a mãe passava por dificuldades e estando desempregados, aceitaram a oferta de um colega para venderem droga. Era o primeiro dia. Pela atividade receberiam R\$ 50,00 por dia. Confirmam que foram abordados. Primeiro Anderson, com o qual foram encontrados dois tabletes de "maconha" dentro de uma pochete e, depois, dentro de uma casa, Edilson, com o qual foram encontradas as demais drogas e as anotações do tráfico.

Pois bem. As provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (laudo e fotografias), além da confissão dos réus, permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável.

Os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que faziam patrulhamento pelo local quando avistaram os réus sentados na calçada. Ao verem a equipe, Anderson permaneceu no local e Edilson correu para dentro de uma residência. Com Anderson foram encontrados 2 tabletes de Maconha. Com autorização do proprietário, entraram no local e encontraram as demais drogas descritas na inicial, além da anotação de tráfico, sob guarda de Edilson.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais e com a própria confissão dos réus.

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, que no dia 05 de janeiro de 2022 e em datas anteriores, em horário incerto, na Rua Sebastião Felipe da Silva, altura do n.º 19, Vila Menck, nesta cidade e comarca de Osasco, ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado à fl. 04, com fotografia à fl. 51, e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado à fl. 05, com fotografia à fl. 52, agindo em associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, traziam consigo drogas, consistentes em 02 (duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 34,49g, 49 (quarenta e nove) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 109,0g, 147 (cento e quarenta e sete) porções de cocaína, com peso líquido de 80,1g, e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 4,33g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas, a quantidade e as condições nas quais se desenvolveu a ação (os réus ao verem os policiais tentaram disfarçar sendo que Edilson correu para uma casa). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com os réus - em pochetes - e se destinava ao comércio espúrio, tanto que foi apreendida anotação. Em que pese haver pequenas divergências nos depoimentos e o fato do réu não ter interagido com

outras pessoas para venda de drogas, estes pontos não são capazes de infirmar a prova produzida e afastar a responsabilidade penal.

Por outro lado, quanto a associação para o tráfico de rigor a absolvição.

Não há nos autos – porque não houve suficiente investigação por parte da autoridade policial – provas de que o concerto delitivo tenha sido estabelecido de forma estável e permanente anteriormente à prática do tráfico, até porque o crime do artigo 35 pressupõe a antecipação da tutela penal exatamente para reprimir que a união prévia de esforço de mais de duas pessoas leve à prática retirada – ou até mesmo isolada – da traficância.

O que se tem dos autos, em verdade, é que os réus estavam, no dia dos fatos, vendendo drogas, entretanto, nada indica um concerto associativo prévio com ânimo de permanência entre os mesmos réus. O que se tem é um concurso de pessoas no qual cada um dos réus contribui com a ação do outro visando um desiderato comum.

B.2 – Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal e ser portador de bons antecedentes (fls. 33/35). Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, não há qualquer elemento que demonstre que o réu se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Este requisito poderia restar demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade policial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações não permite a conclusão de dedicação da ré à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele “não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas”. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 148579 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer à organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta,

qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela. Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

No caso dos autos, não há qualquer mínimo elemento que demonstre de forma pressuposta envolvimento com organização criminosa.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

- corréu Anderson

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a quantidade de drogas é não significativa e, ainda, o ré é primário e não ostenta antecedentes.

Na segunda fase, em que pese a confissão, a pena fora fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por

sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

- corréu Edilson

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que a quantidade de drogas é não significativa e, ainda, o ré é primário e não ostenta antecedentes.

Na segunda fase, em que pese a confissão, a pena fora fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 dias multa.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, posto que não é reincidente em crime doloso, o crime não é praticado com violência ou grave ameaça e, no caso do tráfico, a vedação de conversão foi julgada inconstitucional (HC 97.256/RS) e, ainda, o fato de que a substituição se mostra suficiente e a medida é recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos mais multa.

A restritiva de direitos consiste no cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. A multa, por sua vez, consiste no pagamento de 10 dias-multa.

Somando-se as multas chega-se ao total de 177 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal, o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação penal e:

CONDENO ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificados nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo mesmo prazo, e ao pagamento de 177 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração aos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

ABSOLVO ANDERSON DO NASCIMENTO ANCELMO e EDILSON DO NASCIMENTO ANCELMO, qualificado nos autos, da acusação de terem infringido o art. 35 da Lei n. 11.343/06, com

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

E - Demais deliberações

Pela natureza da sanção os réus poderão recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Autorizo da destruição os objetos. Oficie-se.

Com relação ao dinheiro declaro a perda em favor do estado.

Elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 17 de outubro de 2022.